

1500290-04.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

JEFERSON SILVA DOS SANTOS

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JEFERSON SILVA DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, . - Centro

CEP: 09040-906 - Santo André - SP

Telefone: (11) 4573-3270 - E-mail: stoandre3cr@tjsp.jus.br

1500290-04.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500290-04.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

JEFERSON SILVA DOS SANTOS

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JEFERSON SILVA DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sustenta a denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 15h45, na Avenida Tortusa, altura do nº 53, Sítio dos Vianas, nesta cidade, o acusado transportava, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, 22 invólucros plásticos contendo 4,0 g de COCAÍNA; 45 invólucros plásticos contendo 30,1g de COCAÍNA; 16 invólucros plásticos contendo 6,8 g de COCAÍNA; 02 invólucros plásticos contendo 4,2 g de COCAÍNA, 30 invólucros plásticos contendo 39,5 g de MACONHA; 12 invólucros plásticos contendo 2,7 g de MACONHA; 29 invólucros plásticos contendo 3,8 g de MACONHA; no total de 85 invólucros plásticos com o total de 45,1g de cocaína e 71 invólucros plásticos contendo o total de 46g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra que policiais civis faziam diligências no local quando avistaram três jovens,

sendo que um portava uma bolsa a tiracolo e uma pochete. Com a aproximação da viatura, dois indivíduos fugiram e o indiciado JEFERSON foi abordado. Em revista pessoal, na bolsa encontraram a quantia de R\$ 115,85 e no interior da pochete os entorpecentes supracitados e uma folha contendo anotações. O comportamento do indiciado, a quantidade, a forma como as drogas estavam embaladas, e as circunstâncias em que os entorpecentes foram apreendidos demonstram que eram destinados à comercialização ou o fornecimento gratuito.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 55/57).

A defesa prévia foi apresentada (fls. 136/137) e a denúncia, recebida (fls. 147). Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado confessou a prática do crime.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, com imposição do regime inicial fechado e elevação da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência, e a defesa técnica, pela imposição da pena no mínimo legal, sobretudo diante de seu estado de miserabilidade, com aplicação dos redutores da menoridade relativa e da confissão e da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tudo com regime diverso do fechado.

A folha de antecedentes atualizada foi acostada a fls. 40/41 e há certidão de distribuição a fls. 37/39.

Fundamentação

Materialidade e Autoria

A materialidade da ação criminosa restou demonstrada pelas provas pericial e oral produzidas.

As declarações dos policiais civis em juízo confirmam a apreensão do total de 85 invólucros plásticos com o total de 45,1g de cocaína e 71 invólucros plásticos contendo o total de 46g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Caio Fernando Vasconcelos Ribeiro disse que estava fazendo diligências no bairro, subiu uma rua de conhecido comércio de drogas, avistando JEFERSON com algo nas mãos. Subiram a rua e dois indivíduos saíram correndo. JEFERSON ficou, foi abordado e questionado, confessou portar drogas em uma bolsinha (cocaína, maconha e crack). Na bolsa havia também dinheiro. Havia variedade e quantidade considerável de droga. Ele disse que estava vendendo drogas no local. Na subida da rua íngreme, duas pessoas perceberam se tratar de um carro policial e correram, mas JEFERSON não correu. Os três estavam juntos, conversando. Não conhecia o acusado e nem sabe se ele morava próximo.

Roberto Carlos Rodrigues Pereira disse que estava em diligência no local dos fatos, subindo uma rua íngreme. Visualizou três pessoas conversando em proximidade e JEFERSON estava com uma pochete e uma bolsa a tira-colo. Os outros dois perceberam a aproximação e fugiram, mas JEFERSON foi abordado e com ele localizada a droga. Imediatamente JEFERSON confessou portar a droga e estar realizando a venda. Com ele havia cerca de 115 reais. Foi encontrada maconha e cocaína. Ambos conversaram com o acusado, que disse estar morando na rua, sem arrumar emprego e foi trabalhar na venda da droga. Disse que ganhava 15% do que vendia. A situação demonstrava a traficância, dava a entender, mas não visualizou a entrega de mercadoria ou o recebimento de dinheiro; apenas conversava com dois rapazes, que não sabe se eram compradores ou outros vendedores, passando o turno como confessado informalmente. A própria quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora o quanto atestado pelos agentes policiais no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da

Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercílio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

Deste modo, o porte de tantas porções de maconha e de cocaína, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, conforme atestado pelos agentes policiais, são circunstâncias que permitem afastar o consumo pessoal.

E a autoria delitiva também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos, somando-se à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Como se viu acima, os policiais civis ouvidos em juízo atestaram ter presenciado o acusado em local que lhes seria conhecido como ponto de venda de drogas e, em abordagem, teriam encontrado com ele a droga.

A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. mutatis mutandis HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados.

Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao

momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529).

No caso, a narrativa policial está em consonância com os achados periciais e, especialmente, com a confissão espontânea em juízo.

Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Uma vez que o acusado é reincidente, é inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não exigindo a lei que a reincidência seja específica para afastar o redutor.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. Deixo de valorar os maus antecedentes, não recepcionada a valoração de inquéritos ou processos sem trânsito em julgado pela presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que,

de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga são importantes e não autorizam um juízo favorável ao acusado, pois superiores ao suprimento mensal de um usuário de droga, nos termos já adotados, mas não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena-base.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal) e em razão da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Por conseguinte, atenuo a pena em 1/3 sobre o intervalo de pena em abstrato, que é reduzida para o mínimo de 5 anos.

Deixo de valorar negativamente a reincidência, pois já serviu de critério para o afastamento da causa de diminuição na terceira etapa, evitando-se o bis in idem.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, fixo a pena de multa final em 500 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e da reincidência, bem assim do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o requisito do

artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 4 anos, assim independentemente da idade do acusado ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar JEFERSON SILVA DOS SANTOS à pena de reclusão de 5 anos, em regime inicial fechado, e a 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Preventiva

Nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, aprecio e mantenho a prisão preventiva.

Mantida a prisão durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo imprescindível à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, e ora confirmada, com a condenação, a imputação por crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP), tais requisitos subsistema de forma ainda mais nítida.

Assim, recomendo o acusado à prisão. Expeça-se a guia de recolhimento provisória (art. 8º da Res. CNJ 113/2010).

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06. Comunique-se à autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Int.

Santo André, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA